

0000499-41.2022.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... de acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça. Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA." (TJSP, HC nº 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, j. 05.05.20). g.n.

No mérito, a acusação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000499-41.2022.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000499-41.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO MARCELINO MENDES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

SILVIO MARCELINO MENDES JÚNIOR foi denunciado por incursão no inciso IV do parágrafo 4.º do art. 155 c.c. inciso II do art. 14, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, na data de 25 de janeiro de 2022, por volta das 19h50min, na Rua Rui Barbosa, 31 - Centro, nesta cidade de Mauá, o acusado, em concurso de agentes com Matheus Henrique de Mattos Ferreira, tentou subtrair, para si, a motocicleta HONDA/PCX 150, placa BXM4C90, pertencente à vítima Andressa Dias Neves, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O corréu Matheus já foi julgado nos autos principais nº 1500198-26.2022.8.26.0540.

Recebida a denúncia, o réu Silvio foi citado (fl. 178) e apresentou resposta à

acusação.

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente ouvida. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais, o Ministério Público requer a procedência da ação, enquanto a Defesa insiste no cabimento de proposta de acordo de não persecução penal. No mérito, pleiteia a absolvição ante a insuficiência de provas ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a confissão e a tentativa em seu grau máximo, a imposição de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e Decido.

Destaca-se, inicialmente, que o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu, mas ato discricionário do Promotor de Justiça. No mais, diante da recusa do Ministério Público, os autos foram remetidos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, que insistiu na recusa de oferta do referido acordo (fls. 195-206).

Ressalta-se que o acordo de não persecução penal não pode ser imposto pelo Judiciário em caso de recusa do Ministério Público. Neste sentido precedentes do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Acerca do acordo de não persecução penal, trata-se de uma discricionariedade do Ministério Público, eis que o artigo 28-A do Código de Processo Penal dispõe que: 'Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)'. Ou seja, trata-se de um dispositivo legal não vinculante, não devendo o Poder Judiciário interferir na obrigatoriedade de sua aplicação." (HC 2026314-51.2020.8.26.0000, Rel. Ricardo Sale Júnior, j. 05.04.20). g.n.

"Habeas Corpus. Insurgência quanto à ausência de propositura de acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça. Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA." (TJSP, HC nº 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, j. 05.05.20). g.n.

No mérito, a acusação procede.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls.03-8), boletim de ocorrência (fls. 20-3), auto de exibição e apreensão (fl. 15), auto de entrega e avaliação (fls. 16-7), fotos (fls.31-7), além da prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, na fase administrativa (fl. 14), e em juízo, o acusado manifestou-se (mídia digital).

O policial militar Douglas, na fase antejudiciária (fls.09-10), historiou que: (sic) "no momento dos fatos realizávamos patrulhamento ostensivo com motocicletas

(ROCAM: M-30015-11 e M-30010-11), quando recebemos determinação, via COPOM, para que intensificássemos o policiamento na área central de Mauá, uma vez que, segundo telefonema feito ao nº 190 da Polícia Militar, naquela região haveria ao menos dois indivíduos realizando o furto de motocicletas, sendo que a pessoa autora desse telefonema descreveu tais indivíduos como sendo 2 do sexo masculino, um deles usando capacete na cor branca, o outro capacete na cor preta, sendo que um deles vestia uma blusa 'da Red Bull'; de posse dessas informações, passamos a percorrer as ruas existentes naquele entorno; quando acessamos a Rua Rui Barbosa, altura do nº 31, avistamos dois indivíduos ostentando as características físicas e vestimentas similares às que nos haviam sido transmitidas pelo COPOM, os quais estavam ao lado de duas motocicletas, razão pela qual imediatamente os abordamos, por conta da suspeição também gerada pela inquietude com que passaram a se comportar quando viram nossas viaturas; quando fizemos a busca pessoal nos mesmos, nada de ilícito foi encontrado em poder deles ou sob suas vestes; apenas com o identificado como Matheus Henrique de Mattos Ferreira, achamos no bolso da blusa que usava, um 'cachimbo' de motocicleta; já com Silvio Marcelino Mendes Júnior, nada de ilícito encontramos; percebemos que uma daquelas motocicletas estava ligada, a HONDA/PCX 150, de cor prata e placa BXM4C90; então exigimos a documentação dessa motocicleta, foi quando Matheus e Silvio terminaram revelando que não tinham qualquer documento e confirmaram que estavam furtando a mesma, tanto que já a haviam ligado, danificando a fiação da ignição que acessaram por baixo da carenagem e se preparavam para saírem de lá com ela e com aquela outra motocicleta, que se tratava de uma YAMAHA/NEO 125, de cor azul e placa GCW5D78, de propriedade de Matheus Henrique".

No mesmo sentido as declarações do seu colega de farda, o policial militar Victor (fl. 11).

Sob o contraditório, o policial Victor reiterou integralmente a sua versão. Afirmou que visualizou os suspeitos, com as mesmas características informadas via rádio, mexendo em uma motocicleta Honda PCX, que já estava ligada. Informalmente, o réu e Matheus confessaram que estavam furtando a moto (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

A qualificadora do concurso de agentes restou devidamente provada pela prova oral colhida.

Dentro deste espectro, de rigor a condenação.

Passo à dosagem das penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base do réu no

mínimo legal, qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão, não espontânea, de quem foi preso em flagrante, subtraindo a moto da vítima, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobeja seria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação

mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos

abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era mesmo o caso de reconhecimento da confissão, já que parcial e não foi utilizada para convencimento do Juízo, que fundamentou: "não incidência da confissão em relação ao réu Rodrigo, uma vez que ao negar a participação dos corréus Wallace e Paulo, pretendeu ludibriar o Juízo, faltando com a verdade". Assim, a admissão parcial do fato não foi utilizada para formação de convicção do D. Juízo sentenciante, que se limitou a transcrever a versão dada pelos acusados, valendo-se, para se inclinar pela condenação, dos relatos da vítima, dos agentes policiais e da adolescente." (TJSP, Apelação Criminal nº 0013449-58.2017.8.26.0348, Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, j. 9 de março de 2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravos regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Da leitura

da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 613736/RJ, QUINTA TURMA, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. em 30/03/2021, DJe 13/04/2021).

Ainda assim, a reprimenda não poderia ser conduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na sequência, diante da tentativa, observado o iter criminis percorrido -o réu já estava com a moto da vítima ligada, pronto para fugir, quando foi abordado pelos policiais- procede-se a diminuição da pena em 1/3, definindo-se a condenação em 01 ano e 04 meses de reclusão e 06 dias-multa.

O valor do dia multa será o unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena do réu será o aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do par. 2º, do citado dispositivo legal, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, na forma a ser definida pelo juízo da execução, e prestação pecuniária consistente no pagamento de um salário mínimo a instituição beneficente (com destinação social), a ser indicada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu SILVIO MARCELINO MENDES JÚNIOR, qualificado nos autos, a cumprir pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a sanção corporal na forma acima especificada, e a pagar 06 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso IV do parágrafo 4º do art. 155 c.c. inciso II do art. 14, ambos do Código Penal.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA